

1500062-62.2022.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... sobre a destinação da droga (tráfico ou uso pessoal); a versão defensiva sobre o amplo uso de maconha é crível; não há outros elementos que indicassem tráfico; LUCAS é usuário de drogas; o Réu deve ser absolvido; em caso de condenação, a pena base deve ficar no mínimo legal e deve ser reconhecida a incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; deve ser assegurado ao Réu o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Ilhabela-SP - cep 11630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500062-62.2022.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500062-62.2022.8.26.0626

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019359/2022 - DEL.POL.ILHABELA, 22575043 - DEL.POL.ILHABELA, 187/22/302 - DEL.POL.ILHABELA, 2019359 - DEL.POL.ILHABELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS NUNES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia em face de LUCAS NUNES DE OLIVEIRA pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com a denúncia: no dia 21 de janeiro de 2022, às 07h45min, na Avenida Coronel Vicente Faria Lima, nº 1964, bairro Reino, nesta cidade e comarca de Ilhabela, LUCAS NUNES DE OLIVEIRA guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 03 (três) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 1.072,42g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; na data dos fatos, policiais civis, contando com o apoio de policiais militares, se deslocaram até a residência do denunciado para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500711-

34.2021.8.26.0247; Durante o cumprimento da diligência, os policiais localizaram, mais

precisamente no interior do cesto do carrinho de bebê, 02 (duas) porções de maconha, assim como uma balança de precisão. Outrossim, também foi localizada 01 (uma) porção de maconha que estava no interior da geladeira.

Às fls. 107/109, houve o recebimento da denúncia.

Às fls. 105/106., o Réu apresentou resposta à acusação.

Às fls. 134/136, foi negada a absolvição sumária e designou-se audiência de instrução e julgamento.

Em 08/06/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em suas alegações finais, o MP defendeu que: o Réu deve ser condenado; a versão do Réu não é crível; a entrada no domicílio foi lícita; na dosimetria, a pena-base deve ser exasperada em virtude da grande quantidade de droga; não há atenuantes nem agravantes a reconhecer; não deve ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; o regime inicial deve ser o fechado; a prisão preventiva deve ser mantida.

Em suas alegações finais, a defesa afirmou que: há dúvida fundada sobre a destinação da droga (tráfico ou uso pessoal); a versão defensiva sobre o amplo uso de maconha é crível; não há outros elementos que indicassem tráfico; LUCAS é usuário de drogas; o Réu deve ser absolvido; em caso de condenação, a pena base deve ficar no mínimo legal e deve ser reconhecida a incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; deve ser assegurado ao Réu o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da autoria e da materialidade

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas nas modalidades guardar e ter em depósito.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que a despeito das alegações da defesa técnica, as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 demonstra que foram apreendidas na posse do Réu 2 tijolos e um tablete de maconha.

Anote-se que, conforme conclusões do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 13/14 e 95/97, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 132/133 constatou que são substâncias entorpecentes as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Trata-se precisamente de maconha em 1.019g de massa líquida (fls. 95/97).

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado LUCAS NUNES DE OLIVEIRA foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha WILIAN CARLOS DOS SANTOS afirmou que: foi solicitado apoio pela PCSP para cumprimento de mandado; prestou apoio com a equipe; no local, foram localizados 2 tijolos de maconha e outra quantidade; não lembra a razão da expedição de mandado; os tijolos estavam num carrinho de criança; a outra quantidade o Réu falou que estava no interior da geladeira; não lembra se foi encontrado dinheiro na residência; não se recorda se foi encontrada balança ou

sacolé; depois de a droga ser localizada, o Réu falou que a droga era dele e falou que tinha mais na geladeira; nunca havia abordado o Réu; não conhecia o Réu; na data dos fatos, trabalhava há pouco no município.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha ROGERIO STIEVANO afirmou que: foi um cumprimento de mandado de busca e apreensão; no local, encontraram entorpecentes na casa de LUCAS; as drogas estavam num carrinho de bebê (2 tijolos de maconha) e 1 balança de precisão; na geladeira, encontraram uma porção de maconha também; LUCAS confessou que a droga era dele; falou que havia pego de uma pessoa que foi entregar, mas não deu detalhes; havia uma investigação sobre os furtos ocorridos em Ilhabela; diante dessa investigação, pediram um mandado de busca e apreensão na casa dos suspeitos; o Réu falou que a balança era para pesar a droga que havia adquirido.

Em seu depoimento em juízo, a informante BRUNA PONTES DE ARAÚJO afirmou que: vieram em casa; foi tudo muito rápido; houve barulho; bateram na porta; entraram com tudo na casa; começaram a mexer na casa; perguntaram se havia drogas na casa; mexeram em tudo na casa; algemaram LUCAS e BRUNA e levaram até a delegacia; conhece LUCAS há 4 anos; moram juntos há 3 anos; já tinha visto LUCAS com maconha em casa porque ele é usuário; LUCAS fuma desde que se conheceram; LUCAS fuma o dia inteiro; LUCAS era viciado em maconha; LUCAS fumava cerca de 10/15 cigarros por dia; LUCAS não fumava em casa por causa do filho e do fato de a casa ser da família dele; LUCAS guardava a droga na casa, mas nunca tinha visto daquele tamanho; LUCAS sempre trabalhou; nunca suspeitou que ele traficava; o Réu trabalhava das 7h às 00h; o Réu avisava sobre os locais em que ia fumar maconha; não sabia onde o Réu guardava as drogas normalmente; sabia que tinha um pouco de droga na geladeira, mas não do montante que acharam.

Em seu depoimento em juízo, a informante ROSANA APARECIDA NUNES DA SILVA afirmou que: estava trabalhando; quando chegou, viu o Réu algemado no chão; sabia que LUCAS é usuário de maconha; LUCAS usa maconha desde os 13/14 anos; LUCAS fumava bastante; Réu mandava fotos e dava satisfações; LUCAS falava que estava fumando maconha; sentia o cheiro de maconha no carro; chegou a pedir para parar de fumar maconha, pois tinha medo de acontecer o que aconteceu.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha LAÉRCIO JUNIOR GONÇALVES PEREIRA afirmou que: é amigo de LUCAS há anos; não estava por dentro do assunto que resultou na prisão; conhece o Réu desde 2015; sabia que LUCAS fumava maconha, pois fumavam juntos; sempre saíam juntos e fumavam juntos; compravam drogas juntos; LUCAS fumava bastante maconha; quando paravam para fumar, fumavam 3 baseados; eram baseados maiores / mais grossos; maiores que um cigarro normal; LUCAS sempre trabalhou; LUCAS trabalhava numa temakeria; LUCAS não vendia maconha; dependendo de quanto estava o preço, pegava mais ou menos; pegavam para dividir entre os amigos; já chegaram a pegar 1kg juntos para dividir entre os amigos.

Em seu interrogatório, o Réu LUCAS NUNES DE OLIVEIRA afirmou que: confirma os fatos; a porção que foi encontrada na geladeira era a porção do dia-a-dia; as porções maiores foram compradas no dia anterior; pegou e deixou onde foi encontrado, no carrinho; essa comprou na ponte estaiada; pegava em mais quantidade para evitar ir em biqueira; a droga era para consumo e para compartilhar entre os amigos; falou que venderia por pressão policial; normalmente, guardava a droga fora de casa; quando fechou negócio, comprou a balança para pesar a droga comprada; usa esse kg em 40 dias; a investigação era por receptação; LAURO ameaçou na delegacia; não conhece DENIS; RENAN já foi preso por tráfico de drogas; o cigarro de maconha é bem maior do que um cigarro comum;

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que, na ausência de dúvida razoável sobre a parcialidade dos policiais envolvidos na operação, o seu depoimento é um meio idôneo de prova:

Apelação – Furto qualificado tentado – Condenação – Recurso da defesa – Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral harmônica e coesa – Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais,

normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato. (TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos)

Os depoimentos policiais foram coerentes entre si, convergindo quanto aos seguintes fatos: a) houve um cumprimento de mandado de busca na casa do Réu; b) no local, foram encontrados guardados/em depósito tijolos e um tablete de maconha, em poder do Réu.

Ao contrário do argumentado pela defesa técnica, não é viável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

O TJSP tem precedentes no sentido de que não deve haver a desclassificação quando as circunstâncias da conduta indicarem que o agente, surpreendido em posse de drogas, não o fazia para uso próprio:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e a variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais

quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500579-91.2021.8.26.0597; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Parcial razão. Materialidade e autoria indubitadas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia consigo 07 (sete) eppendorfs de cocaína, com peso bruto de 4,72g (quatro gramas e setenta e dois centigramas) e 01 (um) tablete de maconha, com peso bruto de 500,06g (quinhentos gramas e seis centigramas). Prova oral robusta. Inviabilidade de desclassificação para o uso próprio. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria comporta reparos. Quantidade de entorpecentes apreendida não ultrapassa a normalidade à espécie, devendo manter-se o aumento da basilar apenas com relação aos maus antecedentes, na fração de 1/6 (um sexto). Comprovada reincidência. Impossível a concessão do privilégio. Não preenchimento dos requisitos legais. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500181-14.2021.8.26.0123; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Recurso da defesa - Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Conduta criminosa verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante - Suposto usuário de drogas admitiu na fase inquérito que o acusado lhe vendeu parte da droga apreendida - Desclassificação para o artigo 28 da Lei Drogas - Impossibilidade - Contexto fático não sugere que a droga seria para o consumo do acusado, mesmo porque 4 porções de cocaína foram apreendidas na posse de terceiro, após o acusado tê-las vendido - Presentes os requisitos do "privilégio" (§ 4º do artigo 33 da Lei de Drogas), deve a diminuição de pena ser feita na fração máxima (2/3) - Inviabilidade de se operar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como modificar o regime semiaberto, porquanto, no curso desta ação penal, o acusado foi condenado outras duas vezes pelo mesmo crime - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1501281-78.2020.8.26.0530; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

No caso concreto, o fato de ter sido apreendido mais de 1kg de massa líquida de maconha indica que a conduta do agente não se amolda ao art. 28 da Lei de Drogas,. Por mais que não haja dúvidas que o Réu é realmente usuário de maconha, a quantidade apreendida é incompatível com o uso mencionado (o Réu chega a dizer que consumiria 1kg em 40 dias, o que não é crível).

Por isso, é inviável a desclassificação pretendida.

Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para

o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack - Réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes - condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria - Pena-base fundamentadamente exasperada - Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos)

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu LUCAS NUNES DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto a culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu LUCAS NUNES DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: tratam-se de acusados sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: não há excepcionalidade que justifique a majoração da pena-base pela natureza ou quantidade da droga.

Assim, a pena-base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, é preciso reconhecer a agravante da reincidência (condenação no processo de n. 0000236-31.2016.8.26.0247, conforme certidão de fls. 33/34).

No caso concreto, tendo em vista que o agente confessou a posse da droga, mas afirmou que ela se destinava a uso pessoal, não é possível aplicar a atenuante da confissão:

Súmula 630 (STJ). A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Desta forma, não aplico a referida atenuante.

Por isso, majoro a pena-base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Quanto à terceira-fase, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que exige a presença de quatro requisitos para a diminuição da pena: a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) ausência de dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa.

O STJ entende que a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida com base em inquéritos policiais e ações penais em curso, sem que isso represente violação à presunção de inocência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

- A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

- A Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, a forma como se deu a prisão em flagrante (precedida de investigação pela prática de outro delito que resultou em mandado judicial de busca e apreensão domiciliar), a quantidade e a forma de acomodação do material entorpecente apreendido e o fato de o agravante responder a outras ações penais sugerem a sua

dedicação às atividades criminosas, impedindo a aplicação do benefício. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 684.376/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (grifos acrescidos)

Já o STF tem precedentes em sentido contrário:

PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.

(HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020) (grifos acrescidos)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em "investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional" (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018) (grifos acrescidos)

Como ponto de partida, entendo que, em princípio, inquéritos e ações penais em curso não podem afastar a causa de diminuição de pena.

Por outro lado, há situações em que se pode verificar, mesmo sem o trânsito em julgado, que há dedicação a atividades criminosas: a) prisões em flagrante repetidas em curto espaço de tempo; b) sentença condenatória proferida em outro processo; c) as circunstâncias do caso concreto indicarem que não se trata de uma conduta pontual ou iniciante e que há efetiva dedicação a atividades criminosas.

No caso concreto, nota-se que o agente é reincidente (condenação no processo de n. 0000236-31.2016.8.26.0247, conforme certidão de fls. 33/34)., razão pela qual não é possível aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Por isso, não aplico a causa de diminuição de pena e fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal e a ausência de decurso do prazo do art. 112 da LEP, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela aplicação de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pois não há dados sobre a situação econômica do réu.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I) e a suspensão condicional da pena (art. 77).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o Réu LUCAS NUNES DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 500 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação acima.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes atribuídos ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. EXPEÇAM-SE guias de execução provisória. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020.

Considerando a demonstração de que o dinheiro apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos às fls. 11/12.. Some-se a isso o fato de que O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).

Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia e do bem em favor do FUNAD.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação",

arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ilhabela, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA